

1503469-98.2021.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... não ter recebido denúncias sobre o tráfico de drogas contra o acusado, e que estavam no local investigando fatos que nada tinham a ver com tráfico.

Subsidiariamente, requereu que se considere a primariedade técnica do acusado, aplicação do tráfico privilegiado, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503469-98.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503469-98.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2312068/2021 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 21420928 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2312068 - 03º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS KAUE CASTRO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de LUCAS KAUE CASTRO DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso no caput do art. 33 da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia (fl. 1-2):

Consta dos presentes autos de inquérito policial que, no dia 16 de novembro de 2021, por volta de 16h00min, na Rua Antônio Benedito Teodoro, nº 1, Jardim San Marino, nesta cidade e comarca de Santa Bárbara d'Oeste, LUCAS KAUE CASTRO DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 26, trazia consigo, para fins de comercialização, 22 microtubos contendo cocaína, com peso aproximado de 15 gramas, e 02 porções de maconha, pesando aproximadamente 2 gramas (conforme auto de exibição e apreensão de

fls. 14/15 e autos de constatação preliminar de fls. 16/17 e 19/20), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fl. 113) e apresentou defesa prévia (fls. 103-105), sendo a denúncia recebida (fls. 114-115) e o réu citado e intimado (fl. 148) para a audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu.

Ao fim, o Ministério Público pediu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Quanto a dosimetria, pediu o aumento da pena base em virtude da natureza da droga. Pediu o afastamento do tráfico privilegiado pois o acusado ostenta uma condenação em primeiro grau por tráfico de drogas e passagens anteriores na infância. Pediu fixação do regime semiaberto e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição por falta de provas, alegando não ter sido o réu surpreendido em atos de venda e nem preso com grande quantia de drogas. Alegou ainda que os policiais alegaram não ter recebido denúncias sobre o tráfico de drogas contra o acusado, e que estavam no local investigando fatos que nada tinham a ver com tráfico. Subsidiariamente, requereu que se considere a primariedade técnica do acusado, aplicação do tráfico privilegiado, regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Assim dispõe o artigo 33 da Lei n. 11.343/06:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 25-28), auto de exibição e apreensão (fls. 17-18), e laudos periciais de fls. 108-110 que resultaram positivos para as drogas encontradas e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha Rogério dos Santos, policial militar, disse em juízo que estava em atendimento a ocorrência quando entrou na rua, conhecida por tráfico de drogas, e o réu, ao avistar a viatura, arremessou algo para cima de um caminhão que estava estacionado e tentou fugir, sendo abordado. Em revista pessoal localizaram a quantia de 12 reais e 25 centavos. Retornaram no local em que ele havia dispensado algo no caminhão, foi localizado um invólucro plástico contendo 22 porções de cocaína e 2 porções de maconha. O réu negou os fatos, mas o depoente viu com certeza o acusado arremessando o objeto no caminhão, e tem certeza absoluta que a droga encontrada é o objeto que localizaram posteriormente. O réu em momento algum confessou o delito, pelo menos é o que se lembra. Não conhecia o acusado. Ele estava sozinho no momento da abordagem.

Também policial militar, a testemunha Ed Carlos Santana Dias da Silva disse que no dia dos fatos a equipe foi acionada para atendimento de ocorrência no bairro. No deslocamento, ao adentrar rua já conhecida pelo tráfico, o réu visualizou a viatura e jogou um objeto plástico em cima de um caminhão, sendo ele detido logo depois. Voltaram até o local em que o objeto havia sido arremessado e localizaram, sobre o caminhão, as drogas que foram apreendidas. A princípio o réu negou os fatos imputados a ele, sendo levado ao distrito policial. Não presenciou o réu

confessando. Disse que a ocorrência que iriam atender originalmente era uma desinteligência.

Em seu interrogatório, o réu Lucas disse ter 19 anos, negou a prática delitiva. Contou que estava no local para pagar uma dívida com uma mulher num mercado, passou perto do caminhão, não jogou nada em cima do caminhão. Recorda-se apenas que jogou um papel de bala no chão. Não conhecia os policiais, acredito que eles podem ter se enganado. O dinheiro que estava consigo era troco do mercadinho.

Assim, tem-se de um lado a versão apresentada pelo acusado, de que as drogas não lhe pertenciam e que jogou apenas um papel de bala no chão, e, de outro, o depoimento dos policiais, que afirmaram com absoluta certeza que visualizaram o réu arremessando o objeto na lona do caminhão.

Neste sentido, é de se observar que os depoimentos dos policiais foram uniformes e coerentes, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

Não há nestes autos qualquer elemento para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, que afirmaram nem mesmo conhecer.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Ademais, como se sabe, o depoimento dos policiais não possui presunção de veracidade absoluta, porém, quando coeso com o restante da prova, não havendo qualquer circunstância a lhe desautorizar deve ser levado em consideração.

E é justamente esse o caso em análise, afinal, toda a narrativa dos policiais, repetida de maneira coesa na fase inquisitorial e sob o manto do contraditório, demonstra-se crível e em conformidade com a prova material juntada aos autos.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Estado de São Paulo e do STJ:

Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de diversas porções de entorpecentes variados - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas palavras - Negativa isolada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente - Redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Bis in idem - Inexistência - Regime prisional fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido com o acolhimento daquele apresentado pelo Ministério Público.

(TJSP; Apelação Criminal 1500492-93.2019.8.26.0569; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 10/05/2021; Data de Registro: 10/05/2021)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/11/2016.

Ademais, a versão apresentada pelo réu é pouco crível, não sendo possível imaginar que dois policiais confundiriam o arremesse de um papel de bala ao solo com o arremesse de um objeto plástico em cima de um caminhão.

Importante ainda destacar que o tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas nos "verbos" ou "núcleos" do art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga. No caso dos fatos, embora o réu não tenha sido visualizado vendendo o entorpecente, é certo que pelas circunstâncias do caso concreto as drogas destinavam-se à terceiros.

Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso concreto, a quantidade não era compatível com a figura de mero usuário, a forma de acondicionamento indica que a droga estava pronta para venda e o acusado foi visto por policiais militares jogando algo cima da carreta estacionada, o que depois, aliás, apurou-se tratar dos entorpecentes apreendidos. Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Logo, está bem caracterizado o crime de tráfico de drogas, afinal, a prova colhida nos autos é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. A conduta foi ilícita, o réu era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena (art. 68, CP).

Primeira fase da dosimetria.

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, combinado com art. 42, da Lei de Drogas, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie. Poucos elementos foram coletados a respeito da sua conduta social e personalidade, não sendo possível tal valoração. Embora o réu responda a um processo (1512433-70.2021.8.26.0019 – fl. 137), não há trânsito em julgado, não podendo ser valorado negativamente. O motivo do crime é inerente ao tipo em questão. As circunstâncias do crime não são especialmente graves. As consequências, embora gravosas, são inerentes ao tipo penal e, por fim, não há que se falar em comportamento da vítima ante a natureza do crime.

Ainda que a natureza da droga seja potencialmente lesiva, a quantia apreendida, embora não seja ínfima, também não é exagerada, razão pela qual não entendo ser possível a exasperação.

Assim, fixo a pena base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase da dosimetria.

Encontra presente a atenuante da menoridade relativa, já que, o réu era menor de vinte e um anos na data dos fatos.

Porém, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, mantenho-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Terceira fase da dosimetria.

Ausentes causas de aumento.

Presente, todavia, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º do CP.

Isso porque não há provas nos autos que o réu se dedique a atividades criminosas ou íntegra organização criminosa.

Além disso, o réu é primário e não possui maus antecedentes.

Neste aspecto, anoto que o fato de possuir ação penal em trâmite em seu desfavor não pode ser utilizado como maneira de afastar o privilégio, conforme jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. Recurso defensivo visando a absolvição por fragilidade probatória. Requerimento de desclassificação da conduta para aquela prevista pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. 1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confessou. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena

base em seu mínimo legal. Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Súmula n. 231 do STJ. Processo criminal em andamento que não se presta a revelar o envolvimento do réu em atividades criminosas. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Fixação do regime inicial aberto. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Revogação da prisão preventiva com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.

(TJSP; Apelação Criminal 1500370-06.2021.8.26.0571; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2021; Data de Registro: 11/11/2021)

Da mesma forma, não é possível utilizar passagens infracionais como óbice para concessão do benefício, sobretudo por não haver, nestes autos, maiores informações relativas aos referidos procedimentos da infância. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Sentença condenatória. Irresignação da defesa e do Ministério Público. Mérito. Autoria e materialidade devidamente demonstradas com relação aos dois réus. Depoimentos dos agentes policiais que, mesmo sob especial escrutínio, apontam de forma clara o envolvimento do réu Leonardo no tráfico de drogas, o que é confirmado pelas demais provas colhidas nos autos. Incabível a absolvição. Dosimetria. Quantidade de droga apreendida que não justifica a exasperação da pena-base do réu Pablo. Terceira fase. Tráfico privilegiado. Cabimento. Preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento das condutas na figura do tráfico privilegiado, já que os réus são primários, não possuem maus antecedentes, não se dedicam à atividade criminosa e nem integram qualquer organização ou associação para o tráfico. Atos infracionais que não podem ser usados como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, até porque sequer constam informações sobre o suposto ato infracional imputado ao réu Leonardo. Precedentes do STJ e do STF. Regime inicial aberto e substituição por penas restritivas de direito. Possibilidade. Requisitos legais preenchidos. Ausência de hediondez no tráfico privilegiado, que, de qualquer forma, não impediria a fixação do regime aberto e nem a substituição por penas alternativas. Sentença reformada em parte. Recurso ministerial não provido e recurso defensivo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500708-08.2021.8.26.0594; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bauru - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022)

Assim sendo, considerando a quantidade dos entorpecentes apreendidos, reduzo a pena em 2/3, estabelecendo-a definitivamente em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, CP):

Considerando o quantum da pena privativa de liberdade aplicada e as condições pessoais do condenado e, ainda, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo artigo 59, sendo que o condenado não é reincidente, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "c" e parágrafo 3º, do mesmo diploma legal, fixo, para início do cumprimento da pena, o regime aberto.

Esclareço que o regime em tela é cabível em razão de o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.118.533/MS, ter firmado o entendimento no sentido de que o denominado tráfico privilegiado de drogas não tem natureza hedionda. E, de forma unânime, decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Corte responsável pela interpretação da lei federal e sua correta aplicação, acompanhando o entendimento consolidado pela Corte Suprema, que o tráfico de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06) não é crime equiparado a hediondo, cancelando a súmula 512, editada em

2014 após o julgamento do REsp 1.329.088 sob o rito dos repetitivos.

Detração da pena (art. 42 do CP e art. 387, § 2º do CPP)

Deixo de realizar a detração nesse momento porque, em vista do regime aplicado não veria alteração.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP)

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, com fundamento, principalmente, na garantia constitucional da individualização da pena, declarou inconstitucional a vedação à substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos aos condenados pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (HC 97256/RS, Rel. Min. Ayres Britto).

Considerando o montante de pena aplicado, que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis e ademais que o delito não foi cometido com grave ameaça ou violência, verifica-se a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade pelas penas restritiva de direitos. Pelo que SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pelas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, em busca do resgate da autoestima e aptidão para o trabalho do apenado, devendo o Juízo da execução, em audiência admonitória, definir a entidade que será beneficiado com a prestação social alternativa e prestação pecuniária no valor correspondente a 1 (um) salário mínimo, a ser pago à entidade a ser definida pelo juízo da execução, admitindo-se o parcelamento, conforme a situação financeira do réu.

Da suspensão condicional da pena (art. 77, do CP):

Resta prejudicado o sursis em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Fixação do valor do dia-multa (artigo 49, §1º, do CP)

Considerando e a situação socioeconômica do sentenciado, fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser reajustado a partir da data da prática do crime. A pena de multa deverá ser paga nos termos e nos prazos dispostos no artigo 50 do CP, sob pena de execução.

Considerando a quantidade de pena aplicada, a não reincidência do acusado, o regime imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o réu poderá apelar em liberdade.

Não demonstrada a origem lícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu LUCAS KAUE CASTRO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de um ano e oito meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, fixado regime inicial aberto e aplicada a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito de prestação de serviços e prestação pecuniária.

Quanto ao dinheiro apreendido, DECRETO a sua perda em favor da UNIÃO, devendo o valor ser recolhido em favor do FUNAD.

Após o trânsito em julgado:

Comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se o necessário.

Arcará o condenado, com o pagamento das custas do processo, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, porém, nos termos e limites do art. 98, § 3º, do CPC, diante da gratuidade da justiça, que ora concedo.

Proceda-se em relação as drogas apreendidas conforme o disposto no art. 72, LD, no que ainda couber.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Atendam-se às demais disposições do Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça, no que for pertinente.

P.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA